

第二种意见认为,行为人未经批准使用POS机为他人“养卡”,存在货币给付及资金清算行为,属于非法从事资金支付结算业务,扰乱了金融管理秩序,情节严重,构成非法经营罪。但对于“养卡”行为是否属于信用卡套现行为又存在分歧。其中一种意见认为,“养卡”在性质上等同于套现,应根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定处理;另一种意见认为,使用POS机“养卡”与套现均属于非法从事资金支付结算业务,但不同于套现,应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条的规定处理。

笔者认为,行为人未经批准使用POS机为他人“养卡”的行为属于《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”,情节严重的,构成非法经营罪,但该行为不属于利用POS机套现,不应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定,而应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定定罪量刑。

一、利用POS机“养卡”属于“非法从事资金支付结算业务”

2009年《中华人民共和国刑法修正案(七)》第五条对《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项进行修订,增加了“或者非法从事资金支付结算业务”的规定。“非法从事资金支付结算业务”主要是针对非法为他人办理大额资金转移、非法套现等资金支付结算业务情节严重的行为所作的规定。这里的“非法从事资金支付结算业务”,主要是指不具有法定的从事资金支付结算业务的资格,非法为他人办理资金支付结算业务和外币兑换的行为,如为他人非法提供境内资金转移、分散提取现金服务等。根据《支付结算办法》及《防范和处置非法集资条例》的规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经中国人民

银行依法批准，任何单位和个人不得作为中介机构经营支付结算业务或者擅自从事金融业务活动。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定“使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的”属于《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”。本案中，被告人无支付结算资质，为赚取手续费，利用信用卡持卡人无力归还到期欠款将导致失信等不良影响的现状，采取先垫资为信用卡持卡人归还欠款，后使用POS机以虚构交易方式将信用卡额度套出后归还垫付款项的行为，该行为过程中发生货币资金的支付及清算，符合使用受理终端以虚构交易方式向指定付款方支付货币资金的情形，属于“非法从事资金支付结算业务”。

二、使用POS机“养卡”行为不等于信用卡套现

信用卡套现是指利用POS机以虚构交易等方式，将信用卡内的授信额度转化为现金套取出来，行为人向持卡人直接支付现金。信用卡“养卡”行为从行为特征、不同司法解释的出台背景、社会危害性、罪责刑相适应等角度来看，均不等于信用卡套现。

1. 从行为特征上看，信用卡套现是行为人直接向持卡人支付现金，而“养卡”行为中，未向持卡人支付现金，仅是采用虚构交易方式套取资金归还行为人为持卡人垫付的款项。二者在信用卡原有额度、欠款数额、资金流转方式、刷卡操作顺序等方面均存在实质差异。

2. 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定，违反国家规定，使用POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。该条出台的主要原因是随着特约商户领域的不断拓宽和普及，我国信用卡套现案件急剧增长，该类型行为具有极大的危害性，不仅增加了金融秩序的不稳定因素，还给发卡银行带来巨大的信贷风险，

